



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תביעה מס': 270/10

בענין : 1. רחל שמיר
2. רות זלינגר 3. פלדמן גיל יצחק ת.ז. 2464936

כולם ע"י ב"כ עוה"ד אורנה ויזלברג-שמיר
מרח' פלמ"ח 33, חיפה 34558
טל': 04-8258553, פקס: 04-8248555

התובעים

נגד

1. מיכאל וייסבך ואלה
2. יואל לבקוב ויהודית
3. גיל פיינטוך וליאת
4. אלכסיי פודגורניך וסבטלנה

כולם ע"י ב"כ עוה"ד עופר ריבקין ואח'
משד' בן גוריון 6, הסיטי סנטר, חיפה
טל: 04-8507111, פקס: 04-8507999

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

בע"א 2643/97, שלמה גזן נ' בריטיש וק ולוניאלי, פ"ד נ"ז (2) 385 (2003),
בעמ' 400 מדגיש כב' הנשיא א' ברק את ההגינות כחובה מן הדין במימוש זכויות
קנייניות על ידי בעליהן:

"כל בעל זכות (במובנה הרחב) צריך להפעיל את זכותו בתום לב. עיקרון זה אשר מקורו הפורמאלי הוא בהוראות הסעיפים 39 - 61(ב) לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1973 - הוא עיקרון "מלכותי" (בג"צ 1683/83 יבין פלסט נ' בית הדין הארצי לעבודה בירושלים [17]), בעמ' 708 "מצודתו פרושה ... על כלל המערכת המשפטית בישראל" (ע"א 700/81 פז נ' פז [18], בעמ' 742), הוא קובע אמת-מידה אובייקטיבית של התנהגות ראויה במכלול היחסים הבין-אישיים. אכן, הדוקטרינה של תום-הלב "חותכת את משפט ישראל כולו לאורכו ולרוחבו, מלוא כל הארץ כבודה" (השופט מ' חשין ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון (להלן - פרשת רוקר [19]), בעמ' 250). דרישת תום-הלב משמעותה כי בעל הזכות צריך להפעיל את זכותו ביושר ובהגינות. תום-הלב אינו מחייב

בעל הזכות להתעלם מהאינטרס העצמי שלו , תום –הלב אינו מניח "מידת חסידות" (ראו ע"א 148/77 רוט נ' ישופה בניה בע"מ [20], בעמ' 635). תום הלב מניח כי בעל הזכות דואג להבטיח את זכותו , עם זאת תום-הלב מבקש למנוע הפעלת הזכות מתוך התעלמות מקיומו של הצד האחר ובהתעלם מהאינטרס החברתי . אכן, תום-הלב קובע אמת-מידה אובייקטיבית של התנהגות הוגנת של בעל זכות המבקש על רקע האינטרס החברתי הכולל להגשים את האינטרס העצמי תוך התחשבות באינטרס של הזולת".

פסק הדין שדן לראשונה בהרחבה באופן מימוש הזכות הקניינית ובשאלה אם מתחייב גם כאן, כמו בדיני החוזים, תום לב היה רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נ"ה[1], 199 עליו מצאו שני הצדדים – ובדין – להסתמך. באותו פסק דין נדונו גם כן זכויות קנייניות של בעלי דירות בבית משותף . כב' הנשיא ברק מדרג את מדת תום הלב [במשמעות המשפטית של מונח זה] הנדרשת מאדם בעת שמממש זכות קניינית שלו . הנשיא מונה שלוש דרגות לתום הלב , הנגזרות ממידת הזיקה בין הצדדים לאותה הזכות, היינו מממש הזכות למול מי שעלול להיפגע ממימוש הזכות, כשיחסים בין בעלי דירות בבית משותף בינם לבין עצמם מהווים הדוגמא לדרישה לרמת תום הלב הגבוהה ביותר. ואלו הדברים :

"עקרון תום הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם . הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר ומתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל . מעצם מהותו, עקרון תום הלב מהווה אמת מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היחס של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בין בני אדם ... הוא [עקרון תום הלב- צ.פ.] מאפשר למשפט לגשר על הפער בין צרכיו של הפרט לצרכיו של הכלל ; בין האינדיווידואליזם לקהילתיות ... תום הלב אינו דורש כי האחד לא יתחשב באינטרס העצמי שלו ... עקרון תום הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים כל אחד לאינטרס שלו עצמו . עקרון תום הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר...מידת ההגינות מושפעת ממכלול נרחב של שיקול לים...אופיו של האינטרס הנפגע קובע את היקף תחולתו של עקרון תום לב לגביו...לא הרי ההגנה על הקניין של בעל דירה בדירתו בבית משותף כהרי הגנה על הקניין המשותף של בעל הדירה ברכוש המשותף ... היקפו של תום הלב נקבע על פי אופי היחסים בין בעל הקניין לבין ה'אחר'...לא הרי מעמדו של תום הלב ביחסים בין בעל קניין לזר , כהרי מעמדו של תום הלב ביחסים בין בעל קניין לשותפו ; לא הרי פגיעה על ידי אדם שהקשר עמו הוא חד פעמי [כגון מסיג גבול מזדמן] כהרי פגיעה על ידי אדם שהקשר עימו נמשך "

[ההדגשות אינן במקור].

בנסיבות הליך זה , הגם שהתוצאה קשה לכל הצדדים ואני ערה לכך , התנהגות הנתבעים אגב מימוש זכותם להרחיב את דירותיהם לחלוטין לא עולה בקנה אחד עם נורמות תום הלב שהותוו באותו פסק הדין . מתוך מכלול הראיות עולה תמונה

ולפיה הנתבעים שמו לנגד עיניהם את טובתם שלהם בלבד, מבלי שייחסו משקל ולו הקל ביותר לזכויותיהם הקנייניות של מי הנושאים בזכות בעלת אותו משקל, הלא הם התובעים.

עוד אציין כבר בשלב זה שהנתבעים אינם יכולים לרחוץ בניקיון כפיהם לנוכח החתימות של התובעים כמסכימים. בנסיבות כאן לא השתכנעתי שלתובעים כולם, חרף חתימתם על טופס העירייה, היתה מודעות למהות הבניה העומדת להתבצע, אלא החתימה הסתמכה על מידע שנמסר על ידי הנתבעים, בעוד הנתבעים ערים לכך, מחשים ומנצלים זאת לרעה.

העובדות

1. הצדדים להליך זה כולם בעלי דירות בבית משותף ברח' פלמ"ח 9, שכונת רוממה, חיפה המזוהה גם כגוש 11191 חלקה 183. דירות התובעים ממוקמות זו מעל זו במחצית המזרחית של קדמת הבית, ודירות הנתבעים ממוקמות זו מעל זו לכל רוחב החזית הצפונית, הוא עורף הבית. הבית המשותף מונה 3 דירות נוספות, "דירות ראיי" לדירות התובעים, במחצית הדרומית של חזית הבית, אולם בעליהן אינם צד להליך כאן. לפי מירשם המקרקעין בנוי על החלק ה מבנה נוסף, נפרד, ודירותיו גם הן אינן צד להליך.

2. הנתבעים יזמו הליך של הרחבת דירותיהם על ידי בנית "מגדל ממדי"ס" בחזית המזרחית של הבית וכן מרפסות פתוחות בקדמת דירותיהם, היא החזית הצפונית, אצל רשויות התכנון, ואכן קבלו היתר בניה. כאשר החלו בבניה קם קול צעקה מצד התובעים, צעקה שהתבטאה בפניה לנתבעים שיחדלו מהבניה, ומשאלו המשיכו בבניה - בהגשת בקשה לצו מניעה זמני שיאסור עליה. סמוך לאחר מכן הוגש על ידם כתב תביעה. הנתבעים טוענים כי הוטעו על ידי הנתבעים להאמין שהבניה כולה, גם המרפסות וגם הממדי "ס" תבוצע בחזית העורפית/צפונית של המבנה [ובנית המרפסות אכן מתוכננת באותה החזית], ועל רקע זה – וכן על רקע של יחסי שכנות הדוקים במשך שנים רבות, הם נעתרו לבקשת הנתבעים וחתמו על טופס הסכמה להיתר בניה המיועד לרשות התכנון [להלן: **טופס העירייה**]. הסכמה זו ניתנה מבלי שכלל הוצגה בפניהם תוכנית הבניה, אלא רק הסברים כלליים לגביה. התובעים מייחסים לנתבעים חוסר תום לב והסתרת מידע רלבנטי שתוצאתם קיפוח זכויותיהם הקנייניות בדירותיהם.

3. עילת התביעה, כמו גם עילת הבקשה לצו מניעה זמני, היא אפוא הטענה ולפיה הבניה המתוכננת להתבצע על ידי הנתבעים תסב לדירות התובעים פגיעה מהותית במשמעות סעיף 71ג בחוק המקרקעין. בשל כך נדרש הסעד של צו מניעה קבוע ו/או צו הריסה של החלק שכבר בנוי ו/או פיצוי של כל אחד מהתובעים בסך של 44,000 ₪, כשיעור ירידת הערך של כל דירה.

4. כחוט השני בכתב ההגנה מודגשת עובדת יחסי השכנות ההדוקים ששררו במשך שנים רבות בין התובעים לבין הנתבעים. הנתבעים בכתב ההגנה טוענים כי הצעדים אותם נוקטים התובעים הם שמהווים חוסר תום לב לנוכח הסכמה מפורשת וכתובה מצדם, לאחר שמהות הבניה הוסברה לכולם וכן הוצג בפניהם תשריט הבניה. עוד הם טוענים לשיהוי העולה כדי היעדר הזכות לקבלת סעד. ביתר פירוט טוענים הנתבעים כי לא פעלו בהיחבא; כל תהליך קבלת היתר הבניה היה שקוף לתובעים, בידיעתם המפורשת, וזכה לתמיכת מרבית בעלי הדירות בשני המבנים המהווים את היחידה הרישומית של הבית המשותף, ובכללם התובעים. הנתבעים גם לא מוצאים שום הגיון בהרחבת דירתם לעבר החזית הצפונית, שאילו כך עשו היו דירותיהם שלהם נפגעות, חדר אחד היה הופך לא פונקציונאלי, והיתרון של הוספת שטח לדירה, כמוצר-לוואי של חדר מוגן, היה נמחק. הנתבעים הקפידו למלא אחר כל הוראות רשות התכנון לרבות תלית מודעה במקום בולט בבית המשותף בדבר הבקשה שהגישו להיתר בניה, מה שנחשף גם לתובעים, ולמצער לאלו המתגוררים בבית המשותף. הנתבעים תוך שהם מסתמכים על הסכמות התובעים וההיתר שקבלו גם חתמו על הסכם עם קבלן ביצוע שכבר החל בעבודות הבניה.

5. לחילופין טוענים הנתבעים כי גם ללא הסכמה של התובעים יש להם תמיכת הרוב הדרוש מכלל בעלי הדירות לעצם הבניה. ובכלל, הם טוענים, אפילו ישנה פגיעה מסוימת אזי היא לא עולה כדי פגיעה מהותית אלא לכל היותר פגיעה מזערית בחזית זניחה של חדרי שירות ומטבח. הבניה לא תסב לתובעים פגיעה לשימוש הסביר בדירותיהם, לחדירת אור ואוויר אליהן. איזון בין הפגיעה הזו לבין הפגיעה בנתבעים למקרה שהממדי"ם לא ייבנו, בשים לב לחשיבותם מן הבחינה הביטחונית, מחייב העדפת עמדת הנתבעים.

תיאור הבניה המתוכננת

6. בחודש אוגוסט 2010 קבלו הנתבעים היתר לבנית מרפסות תלויות כהמשך רציף של חדרי המגורים [הסלון] בדירותיהם לכיוון צפון ["כיוון ה ואדי" בלשון הצדדים]. המרפסות התלויות הללו אינן במחלוקת.

7. הנתבעים קבלו גם היתר להוספת חדרי מגורים לדירותיהם, חדר לכל דירה, שיהוו מרחבים מוגנים. לפי הדין בניה זו מחייבת הוספת החדרים כשהם יצוקים מקשה אחת זה מעל זה, כשלפחות 70% מהיקפם מהווים יסודות יצוקים בקרקע. היתר הבניה מדגים הוספת הממדי"ם בחזית הצידיית/מזרחית של הדירות. לאותו הצד פונים גם חדרי השירות וכן המטבח של דירות התובעים. הממדי"ם מתוכננים להיבנות במרחק של 3 מ' לכל היותר {לפי תשריט הבניה המרחק הוא 2.90 מ'} מחלון המטבח של דירות התובעים. פסק הדין יתמקד בהשלכה של הבניה על חלונות המטבחים, שכן שם מוסבת לדעתי הפגיעה המהותית. עוד עולה מתשריט ההיתר כי ההשקה של חדרי הממדי"ם עם דירות

הנתבעים היא באורך של 1.40 מ' לצידי הדירות שלהם, וזאת חרף העובדה שאורך המעטפת של דירותיהם משתרע על פני 3 חזיתות ומגיע לכדי 26 מ' לפחות [לפי תשריט היתר הבניה]. לדירות הנתבעים לא מוסבת שום פגיעה, לאמור: אף לא אחד ממפתחי חדרי הדירות שלהם לא ייחסם. בלשון ציורית ניתן לומר כי דירות הנתבעים "לא מקריבות שום קורבן" לצורך הבניה, ובלשון משפטית אזי ההשלכה של הממדי "ם על דירות התובעים היא מהותית בעוד ה"ם נטולי כל השלכה שהיא על דירות הנתבעים. חוסר איזון זה, וכן לנוכח העובדה שלנתבעים קיימות חלופות רבות אחרות למקם את הממד "ים באופן שלא יפגע באף לא אחת מהדירות, או יפגע במידה מסויימת בדירותיהם שלהם ולעומת זאת יפגע פחות מכפי המתוכנן כיום בדירות התובעים, מטה את הכף לעבר המסקנה בדבר היעדר תום לב מצד הנתבעים.

בחינת חומר הראיות לענין ההסכמה של התובעים

8. ההליך החל בעתירה לצו מניעה זמני שנתמך בתצהירים של התובעים, בתצהירים של הנתבעים, ובחקירות נגדיות עליהם. מאחר וגם במסגרת דיון בתביעה לגופה נשמעו עדויות הצדדים אסקור אותן להלן במאוחד.

9. עדות התובעת מס' 1 שהיא בעלת הדירה בקומה העליונה –

(א) בחודש נובמבר 2009 סיפרו לה הנתבעים 1 ו- 3 כי בכוונתם להוסיף ממד"ים לדירותיהם וכן מרפסות תלויות "לכיוון הוואדי" [היינו לעבר החזית הצפונית של הדירה – הבהרה שלי צ.פ.]. על רקע יחסי השכנות המצויינים היא נתנה הסכמתה בעל פה, ולימים – כשנתבקשה לחתום על טופס הסכמה לעירייה עשתה זאת בחפץ לב. היא ראתה בכך הסכמה עקרונית. היא חתמה על הטופס בלי להתעמק בו יתר על המידה ומבלי שהוצגו בפניה תוכניות הבניה. היא לא עקבה אחר תהליך קבלת ההיתר בעירייה מאחר ונתנה אמון בנתבעים שהבניה אכן תבוצע לכיוון הוואדי.

(ב) בתצהיר משלים העידה כי אסיפת הדיירים בה נדונה לראשונה אפשרות של תוספת בניה התקיימה שנה קודם לכן, ביום 12.8.2008. אותה האסיפה, לפי פרוטוקול שנרשם על ידי אחד מבעלי הדירות, העלתה רעיונות לצורך בדיקה אודות היתכנות חלופות בניה שונות.

(ג) בחקירה הנגדית שבה העדה והעידה על אותה אסיפת דיירים. בעלי הדירות שם העלו רעיונות של הרחבת דירות, בנית מעלית, בנית מרפסות, כל אחד לפי צרכיו. כבר שם נאמר לה לדבריה שהבניה ככל שתהיה גם של הממדי"ם וגם של המרפסות תבוצע לכיוון הוואדי "כי יש שטח מאד נרחב לכיוון שם" – עמ' 2 שו' 10, 18 לפרו'. מסיבה זו גם "ישבתי בשקט" בלשונה. העדה לא זכרה את מעמד החתמתה על טופס העירייה, מי משלושת ילדיה היה נוכח בבית, וכן לא מי

מהנתבעים בא לשם כך. העדה עמדה על דעתה שלא הוצגו בפניה תוכניות אלא רק טופס העירייה, עליו חתמה מתוך שבטחה בנתבעים. לראשונה היא ראתה את תוכניות הבניה רק כשבאת-כוחה הציגה אותן בפניה עובר להגשת התביעה. היא אמנם קבלה מכתבים מהעירייה אך לא התייחסה אליהם הואיל וידעה כי הבניה לא אמורה להפריע לה.

(ד) העדה עוסקת בתחום ההוראה במערכת החינוך; אין לה הכשרה או הבנה בתחום ההנדסי.

(ה) העדה נחקרה על הרגלי החיים ואורח החיים היומיומי שלה, בזיקה למידת ההפרעה שהבניה צפויה להסב לה. אינני מוצאת להתייחס לחקירה זו שכן הפגיעה הקניינית נגזרת ממיקום הדירות לעומת מיקום הממדי "המתוכננים ולא מאורח החיים של בעל דירה זה או אחר.

01. עדות התובעת מס' 2 –

(א) עדה זו אינה מתגוררת בבית המשותף; דירתה שנמצאת בקומה האמצעית מושכרת. היא הצהירה כי באסיפת דיירים בה נטלה חלק נבחנו רצונות של שכנים לבניה בכל מיני וריאציות. בנית מעלית למשל נשללה בשל הפרשי הגובה בין הדירות. ואפילו עלתה, ונשללה, אפשרות להוספת דירה תמורת מימון של חיזוק לפי תמ"א 38. בהמשך נתבע מס' 1 שוחח אתה טלפונית אודות הבניה המתוכננת להיות "מאחורנית, לכיוון הוואדי" [לצד צפון – צ.פ.]. לפי תיאום הוא בא לביתה עם טופס העירייה והיא חתמה כהסכמה עקרונית לשיפוץ. את תכנית הבניה ראתה, לדבריה, רק עובר להליכים המשפטיים.

(ב) גם בחקירה הנגדית העידה העדה שבאף לא אחת מאסיפות הדיירים לא הוצגה תכנית בניה קונקרטית. היא סמכה על דברי נתבע מס' 1 ולפיהם הבניה תהיה לכיוון הוואדי. מעדותה עלה כי בקשה לקבל את הסכמת נתבע מס' 1 לבניה עתידית שלה, ככל שתחפוץ בכך. בתצהיר שתמך בבקשה לצו מניעה זמני וכן בחקירתה במסגרת ההליכים הזמניים לא זכרה ש אכן קבלה את הסכמת הנתבע כמו גם הסכמתם של יתר הנתבעים על טופס שנוסח על ידי בנה [נ/5], אם כי בהגינותה אמרה כי לא התעקשה על כך, ובדבריה "לא דאגתי לקבל את זה חזרה" [עמ' 4 שו' 11 לפרו']. בחקירה הנגדית בהליך העיקרי הבהירה שחיפוש יסודי יותר שערכה עם בנה העלה שטופס כאמור אכן נחתם על ידי הנתבעים ושומר אצל בנה.

17. עדות נתבע מס' 1 –

(א) לפי תצהירו במסגרת הליכי הביניים אזי תכניות הבניה גובשו בין ארבעת הנתבעים, שדירותיהם ממוקמות זו מעל זו. לאחר שאלו גובשו הוא פנה ל וועדה המקומית לקבלת דרישות הוועדה במסגרת הגשת הבקשה להיתר בניה. הוא

הונחה בדבר הצורך בקבלת הסכמה של השכנים על דרך של החתמה על טופס מתאים הוא טופס העירייה. על רקע יחסי שכנות מצוינים עמן הוא לקח על עצמו להחתים את התובעות 1, 2.

(ב) כשהוא מצוייד בתשריט דירה טיפוסית שקבל מהא דריכל שלהם הוא פגש את התובעת מס' 1 בדירתה, הציג בפניה את התשריט והסביר לה בצורה מפורשת ומדויקת הן את מיקום המרפסות והן את מיקום הממ "ד. העד ידע להוסיף כי התובעת שאלה אותו אם הממ "ד ייבנה בהמשך למסדרון הקיים בדירתו והוא השיב לה שאכן כן, ואף הדגים זאת על גבי התשריט. לדבריו מעולם לא עלתה אפשרות של בניית הממדי "ס לכיוון הוואדי "בשים לב לצורת דירתנו וחלוקת החדרים בתוכה", ציטוט מתצהירו.

(ג) גם בפני תובעת מס' 2 הציג בדירתה שלה את תשריט הבניה והדגים את מקום הממדי המתוכנן. קודם שחתמה על טופס העירייה בקשה שידאג להסכמה לבניה עתידית שלה מצד כל הנתבעים ולהבטיח זאת על ידי חתימה על מסמך מתאים שבנה ינסח. העד, כמו גם תובעת מס' 2, טעו לחשוב שמסמך כאמור לא נוסח ולא נחתם. במהלך הדיונים עלה שהעד אכן נתן בידה מסמך כזה חתום על ידי הנתבעים.

(ד) בדומה החתים עד זה שכנ ות נוספות, פישר ובאומל, שאף התייצבו למתן עדות.

(ה) בהמשך תצהירו מתאר העד את תהליך יידוע השכנים אודות תהליך הפרסומים של היתר, זאת לנוכח העובדה שלא כל בעלי הדירות בבית המשותף על שני המבנים שלו נתנו הסכמה מפורשת לעירייה.

(ו) העד לא מוצא כי יש במיקום הממ "ד המתוכנן כדי לפגוע בדירות התובעים. מדובר בחזית אחורית לדירותיהם כשהנוף הנשקף ממילא מוסתר בשל טופוגרפיה [קומות נמוכות] ובשל הסתרתו בצמחיה.

(ז) בחקירה הנגדית העיד נתבע זה כי התשריט עמו הצטייד כשנפגש עם התובעות היה תשריט על דף 4A, לא גרמושקה מלאה אלא תשריט של קומה טיפוסית. הוא זכר את מועדי ההחתמה על טופס העירייה: בין התאריכים 22 ל-24 בנובמבר 2009, לאחר שכבר ב-16 לנוב' היה בידי התשריט. על לוח הזמנים הוא למד מתוך קבלה על תשלום שכ"ט שהנפיק האדריכל. התובעות לא חתמו על תשריט שהציג להן אלא רק על טופס העירייה. עוד בחקירה הנגדית נימק העד את חוסר ההיגיון בבניית הממדי בחזית הצפונית, הנעוץ בחסימת חלון אחד שלו, מה שיחייב ויתור על חדר אחד מחדרי דירתו – עמ' 7 שור 36 לפרו'. לדעתו האפשרות היחידה בה ניתן לבנות את הממדי היא זו לפי התכנון הקיים. להערכתו היה בידי התובעות עותק של התשריט שהומצא להן על ידי שכן אחר אשר התנגד לבניה.

(ח) בתשובה לשאלות שהפניתי אני אל העד הוא השיב כי נושא הבניה היה על סדר היום הציבורי של הבית "כבר הרבה מאד זמן . כולם ידעו על מה מדובר " – עמ' 11 שו' 25 לפרו'. כשנתבקש לתאר את הפגישה עם תובעת מס' 1 העיד כי הסביר לה בדיוק מה הם רוצים לבנות , הסביר שאגף הנ תבעים מעוניין לבנות ממ"ד ומרפסת. התובעת שאלה איפה תהיה הבניה "והסברתי לה שאנו בונים את זה בהמשך הפרוזדור שהוא המקום היחיד האפשרי מאחר וזה החדר הארוך שלנו. אנו נאלצים לקצץ את החדר הארוך כדי להגיע לאזור שניתן לבנות ממ "ד". על אותו הסבר במילים אחרות חזר העד גם בעמ' 14 שורות 24 ואילך לפרו'.

(ט) בעדותו בהליך העיקרי אישר העד כי תיאורטית ניתן למקם את הממ "ד במקום אחר אבל חזר וטען כי מעשית זה יהפוך את אחד החדרים לפרוזדור , לחדר צר וארוך . ובלשונו : **"אין שום היגיון שנשקיע בממ "ד ונאבד חדר "**. [ההדגשה שלי – צ.פ.]. העד פסל אפשרות למיקום הממ "ד בצידו הנגדי של המבנה, בחזית המערבית של דירתם מהטעם ששם "נמצא עמוד עם טרנספורמטור מתח גבוה וזה יעמיד את כל דיירי הבניה בסכנת סירטון " לנוכח מרחק של כ-2.5 מ' שיוותרו בין החדר לבין המתקן.

(י) אשתו של העד , גב' אלה וייסבך העידה אף היא. היא הדגישה את יחסי השכנות המצוינים בין המשפחות [למעט משפחה אחת שאינה צד להליך]. התובעת אמרה לה , כשנוכחה על מיקום הבניה בפועל , כי ראתה תשריט אבל לא התייחסה כי סמכה עליהם, על הנתבעים.

21. עדות נתבע מס' 3 –

(א) עד זה הצהיר כי פנה להחתים את התובע מס' 3 כשהוא מצויד בתשריט דירה טיפוסית שקבל מוייסבך . הוא התארח בדירתו של התובע כשגם אשתו היתה נוכחת [תובע זה אינו מתגורר בבנין]. התובע חתם על טופס העירייה לאחר שהנתבע הסביר לו בצורה מפורשת ומדויקת את מיקום הבניה . גם מצהיר זה לא מצא הגיון במיקום הממ "ד בשונה מהמתוכנן בשל הה שלכה על דירתו פנימה , ושלל אפשרות שאי פעם בעבר דובר על מיקום הבניה לכיוון הוואדי [כיוון צפון] בלבד.

(ב) בתשובה לשאלה ש הפניתי לעד הוא השיב כי באסיפת הדיירים במהלכה עלה נושא הבניה דובר חד משמעית שהממ "ד יהיה לכיוון בו הוא הוקם : "אסיפת הדיירים התקיימה בדירה של מר ו ייסבך, הלכנו כל הנוכחים למסדרון והראינו פיזית איפה יהיה הממ"ד" – עמ' 15 שו' 30 ואילך.

37. העידו שכנים נוספים אודות נסיבות החתמתם על טופס העירייה. לא ראיתי לסקור אותן שכן הם לא היו עדי ראיה למעמד ההחתמה של התובעים.

47. ביום 1.2.11 קיימתי ביקור במקום במעמד מי הצדדי ם ובאי כוחם . אני מוצאת לציין את הנתונים העובדתיים הרלבנטיים הבאים :

(א) המבנה בנוי על שיפוע מתון : בחזית – קומת עמודים המאפ שרת חניה ביניהם. בירכתי העמודים נמצאת הכניסה לחדר המדרגות.

(ב) מעלה חדר המדרגות מוביל לדירות . קיים הפרש של מהלך מדרגות אחד בין דירות החזית [ובכללן דירות התובעים] לדירות העורף [הן דירות התובעים], באופן שהדירה העליונה בצד העורף גבוהה יותר מהדירה העליונה בצד החזית.

(ג) חדרי המגורים של דירות התובעים פונים לרח ' הפלמ"ח. לדירות אלו חלונות גם לחזית מזרחית וגם לחזית צפונית. חדרי המגורים של דירות התובעים פונים לשלוש חזיתות כשהעקרית בהן היא ה חזית העורפית וצופים הן על שכונת ורדיה הממוקמת ממול והן על הוואדי המפריד בין שתי השכונות.

(ד) עוד בקומת העמודים ממוקמים מספר מחסנים . מחסנים נוספים וכן מקלט ממוקמים בחלק הנמוך של המבנה , אליו מוליך מהלך מדרגות יורד בחדר המדרגות המ שותף. המקלט ממוקם בחלק המערבי של הבית , מתחת לדירות התובעים. קיר המקלט בחזית זו חף מחלון.

(ה) בפאתי החלקה ניצב עמוד חשמל ועליו מתקן טרנספורמציה.

(ו) לחלונות חדרי המטבח של דירות התובעים מפתח הפונה לעבר המבנה האחר שבנוי על אותה חלקה . דירות התובעים 2 ו-3 נמוכות יותר והמרחב הניבט מהן מצומצם יותר מזה שניבט מחלון המטבח של דירת התובעת 1 שהוא בקומה גבוהה. חלון זה צופה לעבר הו ואדי, שכונת ורדיה , אם כי במידה מצומצמת בהרבה מכפי שהוא נצפה מדירות התובעים [הביקור כלל ביקור בדירת נתבעים מס' 1].

(ז) הבניה כבר החלה : נוצקה הקומה הראשונה של הממ "ד, זו שאמורה לשמש את נתבעים מס' 1.

(ח) התובעים היפנו אותי להשפעה של הממ "ד על מפתחי החלונות של דירותיהם. הנתבעים מנגד היפנו אותי למיקום חדרי השירות בדירותיהם שיוסרתו לחלוטין על ידי הממ"ד, למרחק מחלונות דירת התובעים וכן להשלכה של ממ"ד על דירתם, ויתור על חדר אחד, אילו היה נבנה במקום אחר.

המסקנות העולות מחומר הראיות לגבי נסיבות קבלת הסכמת התובעים

57. לדעתי התובעים היטיבו לבסס את גירסתם ולפיה לא נתנו הסכמה מפורשת שאינה משתמעת לשתי פנים, כזו הנדרשת בויתור על זכויות קנייניות. מנגד הנתבעים לא הרימו את נטל הראיה להוכיח הסכמה מפורשת של התובעים:

(א) כל הצדדים דוברי אמת לגבי השיחות שהתקיימו בבית המשותף במשך זמן רב, לרבות באסיפת דיירי ס במהלכה הועלו רעיונות בניה שונים. אני נכונה לקבל את הגירסה ולפיה באותה אסיפה שהתקיימה בשנת 2008 הצביעו הנתבעים או מי מהם, כשהם עומדים במסדר ון, לעבר החזית הצידית שם צפוי להיבנות מגדל הממדי"ם.

(ב) אולם בהסבר זה אין משום מסויימות במידה לגביה ניתן להסיק הסכמה חד משמעית. לדעתי באותו השלב גם הנתבעים עצמם לא ידעו בדיוק איפה ייבנה הממ"ד לבד מההערכה הכללית שיהיה בצד מזרח, חזית שאורכה כ- 4.50 מ'. התכנון האדריכלי הוא שהציע להם למקם את הממדי"ם באופן שיפגע בדירותיהם שלהם במידה המינימאלית, אם בכלל. התכנון האדריכלי לא הביא כלל בחשבון את ההשלכות של תכנון זה על דירות אחרות; לנגד עיניו היו רק צרכי הנתבעים כלקוחותיו.

(ג) אינני מייחסת לנתבע מס' 1 זיכרון טוב במידה שביטא ב תצהירו אודות הצטיידות בתשריט קומה טיפוסית בעת שהחתים את התובעות על טופס העירייה. העד למשל לא זכר שאמנם פעל לפי בקשתה של תובעת מס' 2, קבל ממנה טופס דאג להחתים עליו את יתר הנתבעים ולשלוח אותם – כשהוא חתום – לבנה. זו פעילות ממושכת ומורכבת הרבה יותר. אין לי בי קורת על כך שלא זכר, אולם לנוכח זאת תמוה שדווקא זכר בדיוק את המועד בו האדריכל מסר לו תשריט קומה טיפוסית. בשולי הדברים אציין כי אין פלא שהנתבעים הסכימו להרחבה עתידית של דירת התובעת; שום הרחבה של דירתה לא משליכה ולו במשהו על דירותיהם.

(ד) עדות זו של הנתבע מס' 1 אינה עולה בקנה אחד עם התאריך המוטבע על התשריט שהוגש על ידי הנתבעים להיתר הבניה. התשריט נושא תאריך 16.12.09, היינו לכאורה בעת שהחתים את התובעות על טופס העירייה [נובמבר 2009] התשריט טרם בא לעולם, וכל שהיה אז בידיו הוא תכנון עקרוני, ובלשון הנתבעים כולם "גיבוש תכניות" [ראו התצהירים מטעמם] וטופס העירייה. אין זאת אלא שהמועדים אותם מציינים הנתבעים לא מסתמכים על זיכרונם אלא על קבלה שהנפיק להם האדריכל, נושאת תאריך 16.11.09, והוצאה על ידו "על חשבון תכנון" [ציטוט מהקבלה]. מסמך זה לא מאשש את הטענה, המסתמכת על זיכרון

בלבד, שכבר באותו מועד היה בנמצא תשריט הבניה , בעוד התשריט מתוארך כאמור למועד מאוחר יותר.

(ה) ההערכה שבמועד החתמת התובעים על טופס העירייה עדין לא היה בידי הנתבעים תשריט היתר הבניה מתחזקת לנוכח עדותו של המהנדס זלניק, שנותרה איתנה גם לאחר החקירה הנגדית, ולפיה רשו יות התכנון דורשות החתמת השכנים גם על טופס העירייה וגם על תשריט בניה – עמ' 1 לפרו'. אילו היה כזה בידי הנתבעים חזקה שהיו מחתימים את התובעים גם עליו.

67. השתכנעתי שהתובעות ולמצער התובעת מס' 1 הסתמכו על ההסבר שקבלו מנתבע 1 ולא על תשריט. ההסבר עלה גם בקנה אחד עם הה סברים הכלליים שניתנו להן באסיפת הדיירים שהתקיימה כשנה קודם לכן, הן הסתמכו על יחסי שכנות מצויינים, מה שהקים בהן את הציפייה לתום לב מצד הנתבעים.

פגיעה מהותית בדירת התובעים

77. לדעתי מיקום הממדי"ם מסב לדירות התובעים פגיעה מהותית במשמעות סעיף 71ג' לחוק המקרקעין. מדובר בקיר שיקום לכל גובהו של הבית, ייתמר מעל דירת התובעת [מאחר ומפלס הגג של דירות הנתבעים גבוה יותר], במרחק של 3 מ' לכל היותר מחלונות המטבח של הדירות, בחזית בה נכון להיום זוכה אותה חזית למפתח רחב ובלתי- מופרע. מאחר ודירות הנתבעים גבוהות יותר מדירות התובעים אזי ההשלכה של מגדל הממדי"ם משמעותית עוד יותר.

87. זאת ועוד; אם דירות הקומות הנמוכות יותר, של התובעים 2, 3 ממילא אינן נהנות ממרחב פתוח משמעותי, וכי מוצדק להרע את מצבן הפיזי עוד יותר?

97. הפגיעה הקניינית אינה נגזרת, לדעתי, מאורח החיים של מי מהתובעים, וכן לא מהשאלה אם מי מהם מתגורר בדירתו או שמא הדירות מושכרות. גם לא מהיקף הצמחייה המצל על מפתחי הדירה. מוסבת פגיעה לדירה עצמה, יהיה המתגורר בה ויהיו בעליה כאשר יהיו.

02. מידות חלון חדרי המטבח הן גדולות באופן משמעותי מהקבוע בתקן¹, ולא מן הנמנע שהן נקבעו בין היתר בשים לב למפתח הרחב שמתאפשר מהן לעבר המרחב הפתוח: וואדי ושכונה מרוחקת, נתונים שמבטיחים היעדר בניה מול אותם החלונות. שלא כמו חדרי שירות שם מפתחי החלונות קטנים יותר, ההשלכה של הבניה על חלונות חדרי המטבח היא מהותית.

12. מצאתי שהפגיעה המהותית בולטת עוד יותר על רקע חלופות אחרות למיקום הממדי "ס", שתהיינה פוגעניות פחות כלפי התובעים, ועדין לא פוגעות כלל בנתבעים. המהנדס זלניק שהעיד מטעם התובעים ונחקר גם בחקירה נגדית ריכז את החלופות בתשריט [מוצג ת 2/], חלופות לגבי כולן ניתן לדבריו לקבל היתר בניה, ואלו הן:

– חלופה א': העתקת הממדי "ס 3 מ' קדימה על אותה החזית תיטיב משמעותית עם דירות התובעים, ולא תפגע בכהוא זה בדירות הנתבעים; לכל היותר יידרש מהם לוותר על אחד משני החלונות של החדר הקיצוני. הנתבעים שללו אופציה זו מהטעם שתחייב אטימת חלון באחד המחסנים הפונה לאותה החזית. הנתבעים בחרו שלא להתעמת עם בעלי אותו המחסן ולא בררו כלל את עמדתו, שלא מן הנמנע היתה נענית על ידו באופן של חילופי מחסנים עם מי מהנתבעים. אלא הנתבעים העדיפו להתעמת עם התובעים, או ליתר דיוק – העריכו שהתובעים לא יתעמתו עמם.

– חלופה ב': אם אכן החלופה הנ"ל לא מסתייעת, איזו מניעה אמיתית היתה למקם את הממדי "ס באופן משיק לקיר המקלט, שם לא היתה מוסבת שום הפרעה לאף לא אחד מדיירי הבית [מודגם בתשריט בצבע חום]? ההסבר שנתן נתבע מס' 1 בדמות הימצאותו של מתקן טרנספורמציה אינו משכנע על שום מה לא מתאפשרת העתקתו. המהנדס זלניק שמסתמך על תשריט הבניה שולל את הערכת המרחק שנשמעה מפי הנתבע, ומעמידה את המרחק שייוותר בין הממדי "ד לו היה נבנה שם, לבין עמוד הטרנספורמציה על יותר מהמינימום המותר בדין. האמת היא שהנתבעים כלל לא שקלו כל חלופה סבירה אחרת, כזו שתפגע בתובעים במידה המצומצמת ביותר, גם אם במחיר פגיע מסויימת בדירותיהם שלהם.

– חלופה ג': אם אכן הרצון הכן בחדר מוגן עמד לנגד עיני הנתבעים איזו מניעה היתה שהוא ייבנה אכן בחלק מחזית דירתם, חזית רחבה המכילה אופציות לרוב? רוחב הצלע הצרה של הממדי "ד הוא 3.20 מ' ואילו אורך חזית הדירות של הנתבעים הוא מעל 14.00 מ' [!]

¹ סעיף 2.21 לתוספת השניה של תקנות התכנון והבניה [בקשה להיתר, תנאים ואגרות] תש"ל-1970 קובע כי שטחם הכולל של חלונות מטבח לא יפחת מ-5% משטח רצפת המטבח. זו גם היתה ההוראה לפי התקינה הקודמת בזמן. השטח המינימאלי של חלון למטבח דירות התובעים הוא 0.50 מ"ר [5% מתוך שטח המטבח שעומד לפי תשריט היתר הבניה על 10.66 מ"ר [4.10 x 2.60]. שטח חלון המטבח בדירות התובעים הוא לפחות פי 3.

22. ההשלכות של מיקום הממדי "ס כיום על דירות התובעים לעומת ההשלכות של הממדי"א אילו הוקמו בסטיה של 2.5מ' לכיוון צפון מודגמות בתשריט שמצורף לפסק הדין כחלק בלתי נפרד ממנו : **הקו הכחול** מדגים את מדת המרחב הפתוח שמתאפשר מחלונות חדרי המטבח בהיעדר ממדי "ס, **הקו הירוק** מדגים את מדת המרחב הפתוח שיתאפשר מחלונות חדרי המטבח אם ייבנו הממדי "ס במיקום המתוכנן לפי היתר הבניה , **והקו האדום** מדגים את מדת המרחב הפתוח שהיה מתאפשר אילו הממדי "ס היו נבנים בסטיה מסוימת צפונה . כמו כן מודגמות **בצבע כתום** שתי חלופות נוספות עליהן העיד המהנדס זלניק שהן נטולות כל השלכה שהיא על דירות התובעים.

32. השיקולים שהינחו את הנתבעים לבחור את מיקום הממדי"ס הינם ציניים, והם שמחזקים את היעדר הגינות ו היעדר תום הלב מצידם : אילו אכן הפן הבטיחותי לנגד עיניהם אזי היה מתחייב שימירו חדר קיים בחדר מוגן , גם במחיר 'הקרבה' של חדר אחד. לכאורה שום נזק לא היה מוסב לדירותיהם שכן מספר החדרים הכולל לא היה משתנה . אולם הנתבעים חפצו בתוצאה מתנשאת של 'גם וגם וגם': גם חדר נוסף, גם חדר שיהיה מוגן , וגם שמירה על הפונקציונאליות המירבית והמיטבית של הדירה המקורית.

בחינת טענת ההגנה בדבר שיהוי -

42. אין תימא כי התובעים לא עקבו אחר הפרסומים והמכתבים שהונפקו על ידי העיריה תוך כדי הליכי היתר הבניה . משהסתמכו על ההסברים שקבלו מהנתבעים הן במהלך האסיפה הכללית והן עובר לחתימה על טופס העירייה, אלו לא הטרידו אותם עוד. טוענים הנתבעים שהתובעים השתהו, 'ישנו' על זכויותיהם גם לאחר שכבר הוחל בבניה , ובכך הגדילו את נזקי הס. התובעים מתגוננים בטענה כי מיד לכשנוכחו בפרוטנציאל הפגיעה הקימו בפני הנתבעים קול זעקה . ממכלול העדויות , ותוך שאני מקבלת את המועדים הנקובים בתצהירי שני הצדדים – שעולים בקנה אחד עם אלו - אני רואה את תרשים הזרימה של האירועים שבאו לידי ביטוי חיצוני ונראה לעין באופן הבא :

(א) 7.11.10 – תחילת העבודות בדרך של חפירה בצד הבית . החפירה נועדה לדברי הנתבעים להסיט קו ביוב.

(ב) 11.11.10 – יציקת יסודות הממדי"ס בקרקע.

(ג) 11.11.10 בצהריים - התובעת מס' 1 שבה מעבודתה ומרימה בפני הנתבעים קול צעקה.

(ד) 11.11.10 בערב – נתבעים מס' 1 נפגשים עם התובעת מס' 1 בדירתה ולמדים על הביקורת שלה כלפי מיקום הממ"ד. העבודות נפסקות.

(ה) 21.11.10 – העבודות מתחדשות.

(ו) 30.11.10 – הוגשה העתירה לצו מניעה זמני.

52. תצהירי הנתבעים כולם מביאים אותה הגירסה באותן המילים, מה שמקשה על ההבנה מה באמת אירע בתקופה שבין 11.11.10 לבין 21.11.10. לכאורה הם הסכימו לעצור את הבניה כדי "לבחון אפשרות האם ניתן לעשות משהו במצב שכבר נוצר" [ציטוט מסעיפים 16, 18 לתצהירים], ואילו באותה הנשימה, בהמשכו של אותו סעיף בתצהיר ים הם טוענים שהעבודות הופסקו בשל חג מוסלמי של פועלי הבנין, מידע שהיה בתחום ידיעתם הבלעדי. טיעון מנוגד זה כשלעצמו נטול תוס לב. אם הפסקת העבודה ארעה לא מהטעם של חיפוש אחר פתרונות מוסכמים אלא בשל חג מוסלמי אזי הנתבעים הולכו את התובעים שולל והעמידו בפניהם מציאות של הקפאה, של היעדר בניה לפי שעה. בנסיבות אלו לפיהן הוטעו התובעים לחשוב שהפסקת הבניה היא לצורך חיפוש אחר מוצא מהסבך, ובאחת - חידוש הבניה, ללא יידוע מוקדם של התובעים גם היא בבחינת חוסר ניקיון כפיים מצידם.

62. את מרוץ הזמן לבחינת השיהוי יש אפוא למנות מיום 21.11.10 הנסיבות מלמדות שהתובעים פנו בתביעה ללא שיהוי ותוך זמן סביר.

המסגרת הנורמטיבית

72. הפסיקה דנה בשאלה אם – בשים לב לזכות הקנין שהוכרה כזכות חוקתית – מקום שנפגעת זכות קניינית זכאי בעליה לסעד של צו מניעה בכל מקרה, או שמא גם מימוש זכות זו נתון לשיקול דעת הערכאה השיפוטית. בפס"ד רוקר נ' סלומון [הובא בפתיח לפסק הדין] מנה כבוד השופט טירקל אמות מידה שראוי כי תנחינה את הפעלתו של שיקול הדעת, כעוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה [מקרקעין/מיטלטלין, בעלות/זכות אחרת חלשה יותר], עוצמתה של הפגיעה בזכות [היקפה ומישכה], ולצידם שיקולים משניים כעוצמת תוצאות הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות, והתנהגותם של בעלי הדין [שם בעמ' 242]. כב' הנשיא ברק הוסיף באותו פסק הדין פרשנות מרוככת יותר, המוסיפה שיקולים אובייקטיביים של האינטרסים ההדדיים של הצדדים לאור נסיבות המקרה. גם ממשנתו הובא לעיל בפתיח. ועוד ראה עש"א 10716-03-10 מיום 31.3.11 אשר לאחרונה אושר בבית המשפט העליון, קבע את חובת מימוש הזכויות בבית משותף בסבירות ובהוגנות.

82. יישום של המבחנים כפי הותוו בפסק דין רוקר מביא אותי למסקנה כי דין התביעה להתקבל. אני ערה לתוצאה הקשה של החלטה זו על כל הצדדים כולם, בעיקר אלו המתגוררים בבית המשותף: יחסי שכנות ארוכת שנים שאופיינו על ידי כל הצדדים כמצוינים נסדקו, אמון הדדי אבד ולצד כל אלו מוסב נזק כספי. הבריאות הפיזית של הצדדים הושפעה גם היא. אין לי גם ספק שלצד פעולות הנתבעים לא נלוותה כוונה להרע לתובעים; נילוותה אך הכוונה להיטיב עם עצמם תוך עצימת עיניים לגבי ההשלכות על התובעים.

92. שקלתי אם נכון להורות על סעד של פיצוי כספי לתובעים. שני עדים מתחום שמאות המקרקעין העידו בפני: בעוד המומחה מטעם התובעים העיד על ירידת ערך של 5% משווייה של כל דירה, שלל המומחה מטעם הנתבעים ירידת ערך בכלל. המומחים גם נחקרו על חוות דעתם. קשה לי לקבל את המסקנה של המומחה מטעם הנתבעים: מרחיק לכת לחשוב שבניה במרחק של 3 מ' מחלונות דירות התובעים באופן שיצומצם המרחב הפתוח של דירות אלו, בחינת 'יש מאין', לא ישפיע על ערך הדירות כהוא- זה. תוצאה זו היא קיצונית מידי. יתרה מכך, פגיעה שמאית בערך הדירות היא רק מרכיב אחד ממכלול הפגיעות המהוות יחד פגיעה קניינית. אפשר שפגיעה שמאית אכן תהיה באחוזים קטנים, אבל הם משליכים קניינית באופן שהופך את הפגיעה למהותית. זה המקרה דנא.

03. מאחר והבקשה להיתר בניה כמו גם היתר הבניה עצמו היה מהלך משותף של הנתבעים כולם, ובהיות ממדי"ם שנבנים זה מעל זה שלובים האחד בשני, ראיתי ליתן פסק דין אחד נגד כל הנתבעים.

סוף דבר

13. ניתן בזה אפוא פסק דין האוסר על הנתבעים יחד ולחוד מימוש בניית הממדי "ם נושא היתר הבניה שמספרו 73/0963/05 בתיק בנין 73/0963, וכן המחייב את הנתבעים יחד ולחוד להרוס את חלק מגדל הממדי"ם שכבר נבנה, לפחות עד גובה רצפת דירת תובע מס' 3, חלקת משנה 1. החיוב הוא לביצוע בתוך 90 יום מהיום.

23. חרף קבלת התביעה מצאתי שלא להשית על הנתבעים הוצאות, בשים לב להוצאות הגבוהות בהן עליהם לשאת ממילא, וכדי להקל עליהם ביצוע פסק הדין.

33. אין מניע ה שהצדדים יגיעו להסכמה בדבר פיצוי כספי על בסיס חוות הדעת השמאיות, והימנעות מהוצאות משפט יש בה כדי להקל גם על מוצא אפשרי זה.

43. הערבות הבנקאית שהפקידו התובעים במסגרת הליכי הביניים תוחזר לתובעים לאחר חלוף המועד להגשת ערעור, ככל שיוגש על ידי הנתבעים ו/או מי מהם.

ניתן בהיעדר הצדדים ביום כט' בתמוז תשע"א [31.7.11]
העתקים יישלחו לבאי כוח הצדדים.

צפורה פיגנבויס
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין